

1501464-21.2020.8.26.0604

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Aristoteles de Alencar Sampaio

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... difusa ou coletiva para viabilizar a prática do tráfico, correta a aplicação da majorante do art. 40, IV, da Lei de drogas, com a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material (STJ - AgRg no HC 676665 / SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe 12/11/2021; ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

1ª Vara Criminal

1501464-21.2020.8.26.0604 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501464-21.2020.8.26.0604

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODOLFO DE FREITAS GAMA

Vistos.

RODOLFO DE FREITAS GAMA foi denunciado como incurso nas penas do art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 16, §10, IV, da Lei 11.343/06, porque, em 27/09/2020, na Rua da Fé, 83, nesta cidade, teria guardado, para fins de tráfico, substância entorpecente que determina dependência química e física, bem como arma de fogo com numeração suprimida, tudo sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

O réu foi citado e apresentou defesa preliminar, tendo a denúncia sido recebida.

Durante a audiência de instrução foi produzida prova oral, tendo sido o réu interrogado.

As partes apresentaram suas alegações finais, tendo o Ministério Público requerido a condenação do réu pelo crime descrito na denúncia, posto entender comprovadas a materialidade delitiva e a autoria; a defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu pela insuficiência probatória e, de forma subsidiária, pela concessão dos benefícios legais.

Após, vieram os autos conclusos.

Relatados. D E C I D O:

A ação penal merece prosperar.

A materialidade do delito de tráfico foi demonstrada pelas fotos de fls. 14/16, pelo auto de apresentação e apreensão de fls. 7/8, em que se descreve o material apreendido na posse do réu. Por outro lado, o exame químico-toxicológico revelou consistir a substância apreendida em entorpecente, concluindo, pois, por sua toxicidade e potencialidade para causar dependência (fls. 156/157). O armamento apreendido foi periciado a fls. 31/32, comprovando-se sua potencialidade lesiva, bem como a numeração suprimida do revólver apreendido. Assim, a materialidade delitiva foi comprovada.

Analiso a autoria delitiva.

Com efeito, o policial TIAGO HENRIQUE ZACARO PEREIRA disse em juízo que estava realizando patrulhamento preventivo pelo bairro e, ao passar em frente a uma imóvel, avistou o réu acompanhado de uma mulher saindo de um carro. Ao perceberem a aproximação da viatura, a mulher caminhou em sentido à esquina da rua, e o réu adentrou à residência de forma acelerada e fechou o portão. Os policiais realizaram o cerco no imóvel e através do muro da casa vizinha, conseguiram ver o réu evadindo-se pelo telhado, não sendo possível abordá-lo. Ao entrarem em contato com a mulher que estava com Rodolfo, ela confirmou que era companheira do réu há cerca de dez anos, e que ele usava a casa para armazenar drogas naquele imóvel. Fizeram então a busca no local. No telhado havia uma bolsa com arma de fogo, um tijolo de cocaína, dois sacos de cocaína e cerca de cinco mil reais em espécie, além de alguns apetrechos destinados ao preparo da droga. No veículo do réu havia microtubos vazios, que o réu estava levando para encher as capsulas com a cocaína e distribuir nos pontos de venda. A companheira do acusado indicou a qualificação dele. Reconheceu o acusado como sendo a pessoa que fugiu do local.

No mesmo sentido foram as declarações do policial RAPHAEL VINICIUS TEIXEIRA DA SILVA, policial militar, que ratificou o depoimento acima e acrescentou que o réu fugiu na ocasião, sendo identificado posteriormente, através dos seus documentos encontrados no interior da residência.

Neste passo, como já declarou o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "Os funcionários da Polícia merecem, nos seus depoimentos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem em defesa coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286), e, ainda, "Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente "(RT 614/275). Além disso, inexistente qualquer razão comprovada e justificada para retirar a credibilidade destes depoimentos policiais, os quais se mantêm válidos e aptos a sustentarem decreto condenatório.

O réu negou a prática do crime. Disse que na ocasião estava separado da sua esposa e passou na casa onde o casal residia para deixar o veículo, pois a sua ex-companheira iria precisar do automóvel. O réu saiu do local e foi para a sua casa e, alguns minutos depois, recebeu um telefonema informando que alguns policiais estavam na residência, acusando-o de praticar tráfico de drogas. A casa onde as drogas estavam pertence ao seu genitor, o réu não estava morando no local à época. Disse que carteira de trabalho dele apreendida ali era antiga. Disse que não tem qualquer envolvimento com esses bens ilícitos.

Analiso os elementos probatórios.

Os elementos probatórios constantes dos autos, forte nos depoimentos dos policiais, consignam inicialmente que o acusado fugiu do local dos fatos e a esposa do acusado relatou que havia algumas coisas ilícitas em sua casa, legitimando a diligência

domiciliar, autorizando reconhecer, ainda, que foram apreendidas as armas e as drogas no telhado da casa do acusado.

Note-se que os policiais viram o acusado fugir dos policiais indo ao telhado da casa dele, fuga que acabou sendo exitosa, e no telhado onde ele estava foi apreendida a bolsa em cujo interior foi apreendida a droga e as armas mencionadas na denúncia. Ora, ao estar fugindo dos policiais pelo telhado da casa e neste lugar incomum ser apreendida a bolsa com as drogas e armas logo em seguida à fuga, somado ao fato de que em seu carro foram apreendidas muitas embalagens vazias para o embalo da cocaína que estava na bolsa, tem-se que deve ser imputada ao acusado a posse das drogas e das armas em questão.

As alegações de que a casa pertencia aos seus pais e a de que o acusado não estava no local dos fatos quando da abordagem da polícia não foram provadas nos autos, como incumbia ao acusado nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, valendo registrar, ainda, que foi apreendido uma carteira de trabalho do acusado no interior da casa (fls. 17/19).

Resta apenas analisar a destinação da droga a fim de capitular a conduta.

Foram apreendidas cerca de três mil gramas de cocaína, bem como balança de precisão própria para a pesagem do entorpecente. A expressiva quantidade de droga apreendida, somadas à apreensão da balança de precisão e de elevado valor em dinheiro (R\$ 53.949,00- fls. 34), indicam que as drogas destinavam-se ao tráfico e não ao consumo próprio.

Assim, a condenação do réu pelos crimes descritos na denúncia é medida de rigor.

Sobre o concurso de crimes, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, se no momento da apreensão, a arma estiver sendo usada como parte do processo de intimidação difusa ou coletiva para viabilizar a prática do tráfico, correta a aplicação da majorante do art. 40, IV, da Lei de drogas, com a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material (STJ - AgRg no HC 676665 / SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe 12/11/2021; AgRg no HC 577.166/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 12/08/2020, DJe 17/8/2020; AgRg no HC 569609 / SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 20/5/2020).

Contudo, no caso dos autos o armamento foi apreendido junto com as drogas, sem que estivesse sendo usado para a intimidação relacionada ao tráfico. Desta feita, "(....) não pode ser aplicada apenas a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006 em substituição à condenação pelos delitos dos artigos 12 e 14 da Lei 10.826/2003, uma vez que foram encontradas em outra casa uma pistola e munições de calibres diferentes, que não estariam sendo usadas como processo de intimidação difusa ou coletiva para viabilizar o narcotráfico, constituindo, pois, delitos autônomos."(STJ - AgRg no AREsp 2014637 / ES - Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA - j. 21/06/2022)

Desta forma, ante a autonomia dos delitos, praticados por meio de mais de uma ação e com desígnios diversos, está-se diante do concurso material de infrações, a teor do art. 69 do Código Penal.

Por fim, ante a apreensão conjunta do armamento e ante a mesma natureza do tipo penal, tem-se que: "Quanto aos delitos previstos nos arts. 16, caput, e 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003 deve ser mantido o reconhecimento do crime único, pois ocorreram no mesmo contexto fático"(STJ - AgRg no REsp 1624632 / RS - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28 abr. 2020), devendo a pluralidade de armas ser avaliada quando da fixação da pena-base.

Passo à dosimetria da pena para ambos os acusados.

A pena-base do crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas será fixada acima do mínimo legal, tendo em vista a especial circunstância de se tratar da droga apreendida de cocaína, entorpecente este que causa dependência química, vulnerando com maior intensidade a saúde pública pelos deletérios efeitos à integridade física dos consumidores da droga, havendo, assim, maior desvalor da conduta do acusado quando comparado, por exemplo, com a conduta relativas a outras drogas, como por exemplo, o cloreto de etila, impondo-se a exasperação da pena. A expressiva quantidade de drogas apreendida, suficiente para a intoxicação de mais de dois mil usuários (cerca de três mil gramas de cocaína) também justifica a elevação da pena. A jurisprudência corrobora este entendimento: "A natureza e a quantidade da droga apreendida, em atenção ao disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, são circunstâncias que, por si só, justificam o aumento da pena-base acima do mínimo legal" (STJ - HC n.º 165.387/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 8-2-2011, DJe 21-2-2011). Fixo, em razão destas circunstâncias, a pena-base em 9 anos de reclusão e 500 dias-multa, no piso legal.

Pela reincidência (fls. 145/147), elevo a pena para 10 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Sobre o redutor do art. 33, §4º, da Lei de DROGAS, tem-se que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação do índice de redução ou até mesmo impedir a sua aplicação da causa de diminuição de pena (STJ - AgRg no HC 562.200/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020), sendo certo, ainda, que é: "Inviável a aplicação do redutor do art. 33, § 4º. da Lei 11.343/06 no caso concreto, pois, apesar da primariedade do acusado, a expressiva quantidade da droga indica sua participação em organização criminosa." (STJ, HC 140.211/MS, 5ª turma, Napoleão Nunes Maia Filho, j. 22.09.2009). Assim, ante a expressiva quantidade de droga apreendida, indicadora de que o acusado tem o tráfico como meio de vida, somado aos maus antecedentes, não se mostra cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, tornando a pena definitiva.

Crime do art. 16 da Lei 10.826/03

A pena-base será fixada acima do mínimo legal, ante a pluralidade de armas apreendidas a vulnerar com maior intensidade a incolumidade pública, que é o bem jurídico protegido pela norma penal. Assim, fixa-se a pena-base em 3 anos e 6 meses de reclusão e dez dias-multa, no piso legal, que elevo pela reincidência para 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, tornando a pena definitiva.

Pelo concurso material de infrações, somo as penas, a teor do art. 69 do Código Penal, perfazendo a pena final 14 anos de reclusão e 510 dias-multa.

O regime de cumprimento de pena será o inicial fechado, tendo em vista a pena cominada, a expressiva quantidade de droga apreendida, a prática de dois delitos graves, somada à reincidência, e, ainda, a circunstância do crime de tráfico de drogas ser por demais grave, sendo certo que atualmente é o crime que mais vêm gerando violência no país, impondo-se reconhecer a necessidade da fixação do regime de cumprimento de pena mais rigoroso. Consigne-se que: "embora a primariedade e o quantum da pena possam permitir, em tese, a escolha de regime mais brando, não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso quando justificado pela quantidade e natureza do entorpecente apreendido, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 33 do Código Penal" (STJ - HC nº 313.085/SP, rel. Min. Joel Paciornik, j. em 21.6.2016)

Em atendimento ao art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, consigna-se que o tempo de prisão provisória em nada altera a fixação do regime inicial de

cumprimento de pena, ante a ausência de prova acerca dos requisitos subjetivos para a concessão dos benefícios legais, que deverão ser buscados junto ao juiz das execuções criminais (art. 66, III, b, da Lei de Execuções Penais).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para CONDENAR RODOLFO DE FREITAS GAMA à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 510 dias-multa, no mínimo unitário, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, art. 16, §10, IV, da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal.

Não poderá o réu recorrer em liberdade porquanto respondeu ao processo no cárcere, subsistindo, ainda, os requisitos ensejadores da prisão decorrente do flagrante a fim de garantir a ordem pública contra novos atentados à saúde pública.

A proibição ao direito de recorrer em liberdade aos réus que respondem presos à instrução vem sufragada pela doutrina como se depreende da lição do jurista Guilherme Nucci: "Réu que aguardou preso a instrução: deve continuar detido, após a prolação da sentença condenatória, mormente se foi aplicado o regime fechado ou o semi-aberto. Se antes do julgamento de mérito, que considerou o acusado culpado, estava cautelarmente recolhido, com mais lógica assim deve permanecer após a condenação."

Por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos não pode ser acolhida, pois, além da quantidade de pena cominada, em se tratando de delito gerador de violência social e familiar, e pelo princípio da suficiência, incide o entendimento jurisprudencial pelo qual: "como se trata de crime de tráfico ilícito de drogas, cuja conduta enseja especial censurabilidade pelos efeitos nefastos na saúde dos usuários e na Saúde Pública de um modo geral, além de servir de elemento propagador e incrementador de toda uma ordem criminosa, que tantos malefícios vêm trazendo à nossa Sociedade, não concedo o regime aberto ou a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos, que não bastariam à reprovação do crime."(TJSP - Apelação nº 0021376-71.2012.8.26.0309 - Jundiaí - Rel. Des. Alex Zilevoski, j. 8.4.13).

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Recomende-se o acusado no local em que se encontra recolhido.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais.

Declaro a perda em favor da União dos bens apreendidos nos autos, pois vinculados ao tráfico de drogas.

P.R.I.

Sumare, 25 de agosto de 2022.

ARISTÓTELES DE ALENCAR SAMPAIO
Juiz de Direito